

1502812-53.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONSECUTÓRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502812-53.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502812-53.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299408/2021 - 06º D.P. GUARULHOS, 21182212 - 06º D.P. GUARULHOS, 665/21/216 - 06º D.P. GUARULHOS, 2299408 - 06º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEAN VICTOR ROCHA DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

JEAN VICTOR ROCHA DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a

denúncia, no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Adianópolis, próximo à Rua Valter Pinto, Bairro Cocaia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agente e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 374 eppendorfs contendo 59,04g de cocaína e 71 porções contendo 19,56g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 e laudo de constatação provisória contendo fotografias a fls. 25/29.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público (fls. 59/60). O acusado foi notificado (fls. 76) e apresentou resposta à acusação (fls. 92/93). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 106/107).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, na primeira fase, pediu fixação da pena base acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas, admitindo a aplicação, contudo, do redutor nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Quanto ao regime inicial, bateu-se pelo aberto, diante da pena aplicada, anuindo com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, requereu, fixação da pena base no mínimo legal, atenuante da confissão, aplicação do redutor do privilégio na terceira fase, posto que preenchidos todos os requisitos legais, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e gratuidade judiciária.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, cujas conclusões foram positivas para Cocaína e Tetrahydrocannabinol, e prova oral.

O réu confessou plenamente a prática delitiva, admitindo que receberia duzentos reais (R\$200,00) para transportar um indivíduo, que o procurou, porque tinha uma motocicleta. Declarou que sabia da droga, não é dependente químico e não tem passagem. A confissão encontrou sólido respaldo probatório. Vejamos.

Os policiais José Veridiano e Ivanei Brito declararam que avistaram o réu na condução da moto e o "garupa" com um volume sob as vestes, em região conhecida por tráfico. O acusado empreendeu fuga na motocicleta e somente parou, quando viu que uma viela não tinha saída. O garupa desceu correndo e dispensou uma sacola, onde foram localizadas as drogas. O réu disse que fugiu justamente porque o comparsa teria confidenciado que estava com algo ilícito. Não conheciam o acusado.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. No data referida, o acusado, uniu-se a indivíduo não identificado e, na posse de centenas de porções contendo cocaína, crack e "maconha" dentro de uma sacola plástica, foi surpreendido por policiais militares que efetuavam patrulhamento de rotina na região afamada pelo tráfico. Evadiu-se na condução da motocicleta Honda CG 150, de placa FFL 8475 e, quando inviável o prosseguimento, seu comparsa seguiu a fuga a pé. O acusado foi abordado pelos policiais ainda

quando tentava desembarcar da motocicleta para fugir. Em vistoria, ao lado da motocicleta os policiais encontraram a sacola contendo as porções de drogas acima descritas.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência, por seu valor relativo, da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(..) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal”. (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

Ademais, os policiais narraram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a atitude suspeita do réu, a fuga sintomática e persistente, a composse das drogas prontas para vendas e a confissão espontânea, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa e não cogitou de motivo para ser supostamente incriminado falsamente. Não é crível, outrossim, que aquela quantidade e variedade de drogas se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em várias porções.

No mais, as provas da posse e destinação são fartas e não era imprescindível a abordagem de destinatário da substância, embora conveniente. Com a fuga, sequer havia possibilidade de tal providência. A medida, de qualquer sorte, poderia frustrar o resultado do flagrante. Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive sobre o liame com o comparsa e as drogas, sobre a composse para vendas e a confissão espontânea. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

Nesse sentido, os relatos dos policiais foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminarem falsamente um desconhecido. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco no flagrante.

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na confissão do acusado, palavra de policial ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, os testemunhos, a confissão, sua reprodução em juízo e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. É possível até mesmo que o usuário comercialize, sobretudo para sustentar o vício. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei.

O acusado, no mais, é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não justificam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 5 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa, diante da primariedade do acusado (fls. 28). A quantidade somente será avaliada na terceira fase para redução menor, a fim de não acarretar bis in idem.

Na segunda etapa, restam prejudicadas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, haja vista a impossibilidade de redução da pena aquém no mínimo legal, nesta fase.

Na terceira etapa, em razão da primariedade e ausência de provas de envolvimento em atividade criminosa, incide a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/3 da pena, resultando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 333 dias-multa. Da mera quantidade de drogas, exclusivamente, não se extrai filiação a grupo criminoso ou mesmo dedicação permanente à atividade ilícita organizada. Embora comum nestes casos, seria necessário elemento concreto convincente a respeito do vínculo. Sequer foi obtida, outrossim, sob o crivo do contraditório, prova da condição de integrante de grupo especializado ou de encargo duradouro e relevante em tal atividade. Assim, considerando a quantidade e espécie de parte do entorpecente (cocaína), mais lesiva à saúde do que outras, de um lado, e a função de pequeno varejo, de outro, a reprimenda é reduzida no patamar intermediário.

Ainda que se observasse o entendimento jurisprudencial de que tais fatores devem ser considerados na primeira fase, tornando letra morta a margem de redução nessa, que sempre seria máxima, seria possível, no caso concreto, também conforme orientação de vários julgados, o emprego de um dos critérios remanescentes (quantidade ou natureza) para definição de percentual menor de diminuição.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, de qualquer forma, no nosso sentir, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase. Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e natureza de parte da droga, não cabe a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas "poderão" ser reduzidas.

Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução - que pode ir aquém do mínimo legal - e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto, o grau de culpabilidade e especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva e danos à saúde destes. Assim, nega-se a diminuição máxima. Em contrapartida, a função desempenhada (varejo e não gerência), a confissão e as condições subjetivas aparentes não se coadunam com a redução mínima. Não havendo mais causas de diminuição ou de aumento, a reprimenda permanece no patamar anteriormente fixado.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista a quantidade da pena, a natureza do crime (sem violência ou ameaça) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena. Sobre a

temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Preenchidos ainda os requisitos do art. 44, do CP, à luz da primariedade técnica e da pena aplicada, e sendo socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado JEAN VICTOR ROCHA DOS REIS, qualificado nos autos, no cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena e prestação pecuniária de um salário-mínimo a uma entidade com função social, especificadas oportunamente pelo juízo da execução, além do pagamento de 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. par. 4º, da Lei n.º 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado, com urgência.

Determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, observada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA